

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ จังหวัด นครราชสีมา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 101/2533

โจทก์

นาย เนือง เสริฐกระโท ก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 83, มาตรา 276 วรรคสอง

ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายไปเที่ยวงานศพที่วัด จนกระทั่งเวลา 21 นาฬิกาเศษจะกลับบ้าน พบจำเลย ล. และ ข. ซึ่งรู้จักกันมาก่อน ล. รับอาสาพาผู้เสียหายไปส่งบ้านผู้เสียหายตกลงไปด้วยแต่เมื่อออกจากบริเวณงานได้ประมาณ 1 เส้น ล. จุด ผู้เสียหายเข้าป่าละเมาะข้างทาง อันเป็นที่เปลี่ยวและมีด แล้วข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ จากนั้น ล. ก็ผิวปากเป็นสัญญาณให้จำเลยกับ ข. เข้าไปข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่อจนสำเร็จความใคร่คนละ 1 ครั้ง ดังนี้ลักษณะการกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าว แสดงว่ามีเจตนาร่วมเป็นตัวการในการปลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหนี้ยิงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 276 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 278, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3 จำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยกับพวก ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรา นางอำนวย บุญสุข ผู้เสียหาย อันมีลักษณะเป็นการ โทรมหญิงหรือไม่ นางอำนวย บุญสุข ผู้เสียหาย เบิกความว่า พบจำเลย นายลิ่ม และ นายเชิด ในบริเวณงานศพ นายลิ่มถามผู้เสียหายว่าจะกลับบ้านหรือยัง หากกลับจะไปส่ง แล้วผู้เสียหายกับนายลิ่มก็เดินออกจากบริเวณงาน ขณะเดินมาได้ประมาณ 1 เส้น นายลิ่มจูงมือผู้เสียหายเข้าไปในป่าละเมาะข้างทาง ผลักผู้เสียหายนอนลงที่พื้น ถอด เสื้อผ้าผู้เสียหายออก ทำการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ จากนั้น นายลิ่มผิวปากเป็นสัญญาณ สักครู่จำเลยและนายเชิดก็เข้ามาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่อจนสำเร็จความใคร่คนละ 1 ครั้ง เห็นว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายไปเที่ยว งานศพที่วัดบ้านนาราก ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี ผู้เสียหายเที่ยวงานจนถึงเวลา 21 นาฬิกาเศษ จะกลับบ้าน พบจำเลยนายลิ่มและนายเชิดซึ่งเป็นคนรู้จักกันมาก่อน เมื่อ นายลิ่มรับอาสาจะพาผู้เสียหายไปส่งบ้าน ผู้เสียหายก็ตกลง เมื่อออกจากบริเวณงาน มาได้ประมาณ 1 เส้น ปรากฏว่านายลิ่มจูงผู้เสียหายเข้าไปในป่าละเมาะข้างทาง ใช้ มือปิดปากผู้เสียหาย ข่มขู่ผู้เสียหายไม่ให้ร้อง ผลักผู้เสียหายนอนลงที่พื้น แล้วข่มขืน

กระทำซ้ำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ หลังจากนั้นนายลิมได้ผิวปากเป็นสัญญาณ
เรียกให้จำเลยและนายเชิดเข้ามาข่มขืนกระทำซ้ำเราผู้เสียหายต่อจนสำเร็จความใคร่
คนละ 1 ครั้ง ขณะเกิดเหตุเป็นเวลาค่ำคืน บริเวณที่เกิดเหตุมืดเป็นป่าละเมาะเปลี่ยว
จำเลยกับพวกอาจซุกซ่อนอาวุธติดตัวมาผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงย่อมมีความตกใจกลัว
เป็นธรรมดาว่าจะถูกจำเลยกับพวกทำร้ายได้หากขัดขืน จึงไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือ
เหลือในสภาพเช่นนั้นผู้เสียหายตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนการข่มขืนกระทำ
ซ้ำเราของจำเลยกับพวกได้ หลังจากจำเลยกับพวกหลบหนีไปแล้ว ผู้เสียหายเดิน
กลับเข้าไปในบริเวณวัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อพบสืบทำรวจเอกกิตติศักดิ์ ศักดิ์สุริยวงศ์ ซึ่ง
กำลังเข้าเวรรักษาความสงบอยู่ในบริเวณงาน ผู้เสียหายก็แจ้งเหตุดังกล่าวให้สืบทำ
รวจเอกกิตติศักดิ์ทราบทันที แล้วพาสืบทำรวจเอกกิตติศักดิ์ตามหาจำเลยกับพวก
พบจำเลยกลับมาเดินอยู่ในบริเวณงานอีกเมื่อจำเลยเห็นผู้เสียหายและสืบทำรวจเอก
กิตติศักดิ์ก็วิ่งหนีอันเป็นพิรุธอย่างยิ่ง ประกอบกับจำเลยนำสืบรับว่าได้ร่วมประเวณี
กับผู้เสียหายจริง แต่บ่ายเบี่ยงต่อสู้ว่าผู้เสียหายสมัครใจยินยอมโดยอ้างว่าผู้เสียหาย
ชักชวนให้จำเลยดื่มสุราจำเลยก็ร่วมดื่มสุราด้วย แล้วนายลิมกับผู้เสียหายพากันเดิน
ออกไป ส่วนจำเลย นายวินัยและนายสง่าไปดูลิเก ขณะดูลิเกนายลิมมาบอกว่าผู้เสีย
หายนั่งรออยู่จำเลยไปกับนายลิมพบผู้เสียหายนอนเปลือยกายอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
ผู้เสียหายชวนให้จำเลยร่วมประเวณีด้วย แต่จำเลยหาได้นำนายวินัยและนายสง่ามา
สืบสนับสนุนให้เห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใดไม่เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ฟังไม่
ได้ว่าผู้เสียหายสมัครใจยินยอมให้จำเลยกับพวกพลัดเปลี่ยนกันร่วมประเวณีกับผู้เสีย
หาย ผู้เสียหายและพยานอื่นของโจทก์ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนเหตุ
ระแวงว่าจะเบิกความปรัปไรใส่ร้ายจำเลยจึงไม่มี พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนัก
มั่นคงฟังได้โดยปราศจากความสงสัยว่าจำเลยกับพวกร่วมกันข่มขืนกระทำซ้ำเราผู้
เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามฟ้องจริง พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้าง
ได้

ส่วนข้อที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้ร่วมหรือเป็นตัวการกระทำความผิดด้วย ไม่อาจลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสองได้นั้น เห็นว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายพบจำเลยกับพวกมีนายลิ่มและนายเชิดอยู่ในบริเวณงานศพ เมื่อนายลิ่มข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ นายลิ่มก็ผิวปากเป็นสัญญาณให้จำเลยและนายเชิดเข้าไปข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่อจนสำเร็จความใคร่คนละ 1 ครั้ง ลักษณะการกระทำของจำเลยและพวกดังกล่าวแสดงว่ามีเจตนา ร่วมเป็นตัวการในการปลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายด้วยกัน เป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสองคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น แต่ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อนาสืบของจำเลยที่รับว่าได้ร่วมประเวณีกับผู้เสียหายนั้น เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษสมควรลดโทษให้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-อุระ หวังอ้อมกลาง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. คดีนี้เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาอีกคดีหนึ่งที่วินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักพอรับฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่ นับเป็นตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับการฟังข้อเท็จจริงได้เป็นอย่างดี ปกติแล้วคดีข่มขืนกระทำชำเรา นั้น ส่วนใหญ่จะมีแต่ตัวผู้เสียหายเพียงปากเดียวเท่านั้นมาเบิกความเป็นพยานของโจทก์แต่ในบางคดี ผู้เสียหายถูกฆ่าตายทำให้ไม่มีประจักษ์พยานก็มิดังนั้นการวินิจฉัยคดีประเภทนี้ จึงมักพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีกับพยานแวดล้อมต่าง ๆ เท่าที่โจทก์พอหามาได้ แล้วศาลจะชั่งน้ำหนักพยานเหล่านั้นว่าเพียงพอลงโทษจำเลยได้หรือไม่ มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีข่มขืนกระทำชำเรา พอเป็นแนวทางให้ผู้สนใจศึกษาถึงการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลได้ดี อาทิ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1/2510 จำเลยถูกฟ้องว่าสมคบกับนายโพธิและนายอ้วนหลอกลวงนางสาวทองไปจากจังหวัดชัยภูมิว่าจะพาไปทำงานได้เงินเดือน ๆ ละ 400 บาท ระหว่างทางบุคคลทั้งสามได้ผลัดกันข่มขืนกระทำชำเรานางสาวทองแล้วพาเข้าโรงแรมเข้าช่องบังคับให้ค้าประเวณี ศาลชั้นต้นเชื่อข้อเท็จจริงดังนี้จึงพิพากษาลงโทษศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษาว่า คดีตกอยู่ในข้อสงสัย จึงพิพากษากลับปล่อยจำเลยโดยยกฟ้องโจทก์ เหตุที่น่าสงสัยคือ มีประจักษ์พยานแต่นางสาวทองผู้เสียหายคนเดียว สงสัยว่านางสาวทองจะตามมาเป็นภรรยานายอ้วนเองเพราะถูกหลอกลวงจำเลยเองก็อาจจะถูกนายอ้วนหลอกมาว่าจะหางานให้ทำเหมือนกันแต่แล้วก็ผิดหวังกลับไป จำเลยเองเป็นผู้ส่งข่าวให้บิดามารดานางสาวทองทราบพฤติการณ์แห่งคดียังไม่พอฟังได้ถนัดชัดเจนว่าจำเลยได้ร่วมกระทำผิดด้วย หมายเหตุ ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีหมายเหตุของนายยิ่งศักดิ์กฤษณจินดาด้วยโปรดดู"นายยิ่งศักดิ์กฤษณจินดา, คำพิพากษาศาลฎีกา 2510, ศรีเพ็ชรการพิมพ์, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 1-2" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2522 ในคดีข่มขืนกระทำชำเรา โจทก์ไม่ได้ตัวผู้เสียหายมาเบิกความ คงมีแต่คำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหาย ซึ่งจะรับฟังประกอบได้ก็แต่เพียงว่าผู้เสียหายได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนเช่นนั้นจริง แต่ความจริงจะเป็นอย่างไร

ในชั้นศาล โจทก์จะต้องมีพยานมาเบิกความต่อศาลว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง เมื่อชั้นศาลโจทก์ไม่มีพยานมาเบิกความว่าจำเลยได้กระทำความผิดโดยชัดแจ้งโดยช่มชัดกระทำความผิดที่เราผู้เสียหายเช่นนี้ เพียงแต่คำให้การชั้นสอบสวนจึงยังฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 617/2526 หลังจากผู้ตายร้องให้ช่วยประมาณ 5 นาทีเศษ ว.กับพวกได้ไปยังที่เกิดเหตุพบรอยหยักราบจากไหล่ถนกลงไปในคูน้ำมีจำเลยซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำ และต่อมาได้พบศพผู้ตายอยู่ห่างจากที่จำเลยซ่อนตัวอยู่ประมาณ 1 ศอก ที่ตัวผู้ตายและตัวจำเลยมีบาดแผลแสดงว่าผู้ตายต่อสู้ขัดขวางจำเลย เมื่อตรวจศพผู้ตายหลังเกิดเหตุประมาณ 7 ชั่วโมงเศษก็พบน้ำอสุจิและตัวอสุจิในช่องคลอดผู้ตายจำนวนมาก สาเหตุที่ตายเพราะขาดอากาศเนื่องจากถูกบีบคอและสำลักน้ำ ข้อเท็จจริงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้ช่มชัดกระทำความผิดที่เราผู้ตายและฆ่าผู้ตายโดยวิธีกดให้จมน้ำจนสำลักน้ำตายเพื่อปกปิดความผิดของจำเลยโดยไม่จำเป็นต้องนำคำรับสารภาพของจำเลยมาประกอบการพิจารณา ดังนั้น การที่จำเลยให้การรับสารภาพจึงหาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอันจะเป็นเหตุให้ได้รับการบรรเทาโทษไม่ เพราะจำเลยให้การรับสารภาพโดยจำนนต่อพยานหลักฐาน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 76/2530 แม้โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานปากเดียวที่รู้เห็นว่าจำเลยกับพวกร่วมช่มชัดกระทำความผิดที่เราผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมด้วยก็ตาม แต่เมื่อพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุให้ควรเชื่อได้ว่าผู้เสียหายเบิกความไปตามความจริงกรณีก็ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้มีหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจของนายจรัญรักดิธนากุล อยู่ด้วย โปรดดู"คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2530 เล่มที่ 1 สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ,บริษัทศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด,2530, หน้า 61-63" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1346/2530 โจทก์มีพยาน 1 ปากที่เห็นเหตุการณ์ขณะชายคนหนึ่งวิ่งไล่เด็กผู้หญิงไป และในมือข้างขวาของชายผู้นั้นมีวัตถุยาวประมาณ 1 ศอกเศษ พยานได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องว่า "กูจะบอกพ่อกู" จุดที่พยานยืนดูเหตุการณ์อยู่นั้น ห่างจากที่คนทั้งสองวิ่งไล่กันประมาณ 200-300

เมตร พยานจึงไม่สามารถจำได้ว่าเป็นใคร แต่ระยะเวลาที่พยานเห็นเหตุการณ์ตรงกับเวลาที่เกิดเหตุพอดี ชายที่วิ่งไล่เด็กผู้หญิงไปก็สวมเสื้อผ้าเช่นเดียวกับที่พยานพบจำเลยหลังเกิดเหตุเพียงเล็กน้อย ซึ่งเมื่อนำไปพิจารณาประกอบกับรายละเอียดในคำรับสารภาพของจำเลยแล้วฟังลงโทษจำเลยได้ หมายเหตุ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276,288,289 ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276,289(7) ฐานข่มขืนกระทำชำเราจำคุก 8 ปี ฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 หนึ่งในสามลงโทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา 5 ปี 4 เดือน ฐานฆ่าผู้อื่นจำคุกตลอดชีวิตจำเลยต้องโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต จึงกำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว (คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2213/2530 ผู้เสียหายถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเรา แต่ไม่กล้าเล่าให้บิดาฟังเพราะกลัวบิดาจะฆ่า เมื่อบิดาทราบความจริงมาสอบถามผู้เสียหายก็ยังไม่บอกแต่กลับหนีไปอยู่จังหวัดอื่น จนบิดาไปตามให้กลับมาแจ้งความ เช่นนี้การแจ้งความหลังเกิดเหตุแล้วหลายวันของผู้เสียหายจึงมิใช่พิรุณถึงกับทำให้คดีโจทก์รับฟังลงโทษจำเลยไม่ได้ หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้มีหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจของนายไพโรจน์ วายุภาพ อยู่ด้วยโปรดดู"คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2530 เล่มที่ 8 สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ,บริษัทศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด,2530 หน้า 148-149" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4536/2530 ผู้เสียหายอายุ 13 ปี ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดปลายแหลมจี้คอและข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง ในที่เกิดเหตุมีด แม้ผู้เสียหายไม่เห็นหน้าคนร้าย แต่จำเลยอ้างได้ว่าเป็นเสียงของจำเลย ผู้เสียหายและจำเลยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกันโดยผู้เสียหายเป็นบุตรแม่เลี้ยงจำเลย ส่วนจำเลยเป็นบุตรพ่อเลี้ยงผู้เสียหาย แม้จำเลยจะเบิกความว่าไม่ค่อยได้พูดกับผู้เสียหาย ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายมีเรื่องโกรธเคืองจำเลยจึง

ไม่มีข้อระวางสงสัยว่าจะแก้งกล่าวหา การที่มารดาผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานโจทก์เบิกความว่า คืบเกิดเหตุผู้เสียหายไม่ได้บอกว่าใครทำ อาจเป็นการช่วยเหลือจำเลย เพราะพยานเป็นมารดาเลี้ยงของจำเลยและอาศัยอยู่กับบิดาของจำเลยย่อมจะต้องมีความเกรงใจบิดาจำเลยเป็นธรรมดา การที่ผู้เสียหายไปแจ้งความซ้ำก็เพราะเห็นว่า ฟังพามารดาไม่ได้เสียแล้ว จึงต้องไปหา ว.น้ำชายให้ช่วยพาไปแจ้งความไม่ปรากฏว่าว. เคยโกรธเคืองกับจำเลยด้วยสาเหตุอะไร ส่วนกางเกงขายาวของจำเลยที่ทิ้งอยู่ในห้องผู้เสียหาย แม้มารดาผู้เสียหายจะเบิกความว่าไม่เคยเห็นก็หาเป็นพินิจทำให้คำเบิกความของผู้เสียหายมีน้ำหนักน้อยลงไม่พยานหลักฐานโจทก์มีเหตุผลมั่นคงบ่งชี้ให้ชัดแจ้งว่าจำเลยเป็นคนร้าย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1458/2531 แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นจำเลยที่ 2 ร่วมข่มขืนกระทำชำเราและฆ่าผู้ตายก็ดี แต่โจทก์มีพยานแวดล้อมซึ่งล้วนแต่เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดกับการตายและการพบศพของผู้ตาย เมื่อฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นสอบสวนแล้ว รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดจริง 2. ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 ได้บัญญัติองค์ประกอบของความผิดไว้ว่า 1) ข่มขืนกระทำชำเรา 2) หญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน 3) โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยหญิงนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ดังนั้นในความผิดฐานนี้จำเลยโดยทั่วไปมักต่อสู้ว่าจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายโดยผู้เสียหายยินยอม เพราะหากข้อเท็จจริงฟังได้เช่นนั้น จำเลยก็ไม่มี ความผิดอาทิ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2238/2527 ความสัมพันธ์ของผู้เสียหายกับจำเลยเป็น คนใกล้ชิดสนิทสนมในลักษณะของคนที่รักกัน ระหว่างไปทำงานที่โรงสีข้าว จำเลยเข้าไปในห้องพักข่มขืนกระทำชำเราต่างวันและเวลากันถึง 2 ครั้ง ผู้เสียหายก็มีได้เอะอะหรือแพรงพรายให้ผู้ใดทราบ แม้แต่มารดาของตนซึ่งไปทำงานแห่งเดียวกัน เพิ่งบอกเมื่อออกจากงานและกลับถึงบ้านแล้วหลายวัน บิดามารดาผู้เสียหายเรียกจำเลยไปสอบถามทำนองบังคับให้ยอมรับผู้เสียหายเป็นภรรยา เมื่อจำเลยไม่ยอมทำ

ตาม จิงกล่าวหาดำเนินคดีแก่จำเลยดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอพียงลงโทษจำเลย
ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 313/2528 ผู้เสียหายยอมให้จำเลยที่ 1 ร่วมประเวณีโดย
สมัครใจ แม้จำเลยที่ 2 จะช่วยจับขังผู้เสียหายต่างออกในการร่วมประเวณีโดยสมัคร
ใจของผู้เสียหาย เช่นนั้นยอมไม่ทำให้การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิด ผู้เสีย
หายยินยอมให้จำเลยทั้งสองมาคุยด้วยบนบ้านในลักษณะเปลือยกายทั้งสองคน และ
ยังยอมให้จำเลยที่ 1 ร่วมประเวณีด้วยความสมัครใจต่อหน้าจำเลยที่ 2 ทั้งที่มีแสง
ตะเกียงเช่นนั้น แสดงว่าผู้เสียหายสมัครใจแสวงสุขในเชิงโลกีย์วิสัยร่วมกับจำเลยทั้ง
สองโดยสมัครใจ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 101/2533 นี้ จำเลยก็พยายามต่อสู้ว่า
ผู้เสียหายยินยอมเช่นนั้นเหมือนกัน โดยพยายามชักค้ำให้เห็นว่าขณะเกิดเหตุผู้เสีย
หายไม่ร้องขอความช่วยเหลือเลยแต่ศาลฎีกาก็ฟังในเรื่องนี้ว่าเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
ผู้เสียหายยอมมีความตกใจกลัวว่าอาจถูกจำเลยกับพวกทำร้าย ผู้เสียหายจึงไม่กล้า
ร้องขอความช่วยเหลือ ถือว่าในสภาพเช่นนั้นผู้เสียหายตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ
ขัดขืนการข่มขืนกระทำชำเราของจำเลยกับพวกได้อันเป็นการเข้าองค์ประกอบความ
ผิดฐานนี้แล้ว มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราในองค์
ประกอบข้อที่ 3 ที่น่าสนใจ คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 143/2454 จุดหญิงไปในป่า
ไม่มีทางที่จะขัดขืน หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใด หญิงจึงจำต้องยอมให้กระทำ
ไม่ถือว่าหญิงยินยอม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2759/2532 ความผิดฐานข่มขืนกระทำ
ชำเรานั้น แม้จำเลยจะไม่ได้พูดหรือมีอาวุธขู่ขู่ผู้เสียหายก็ตาม ถ้าตามพฤติการณ์ผู้
เสียหายกลัวจำเลย ตกอยู่ในอำนาจบังคับของจำเลยตกอยู่ในภาวะจำยอม ไม่กล้า
ขัดขืน จะถือว่าผู้เสียหายยินยอมไม่ได้เมื่อตามพฤติการณ์จำเลยกับพวกร่วมกันจุด
จับแขนขาผู้เสียหายแล้วพาไปปลัดกันกระทำชำเราผู้เสียหายที่ได้สะพาน จำเลยจึง
ต้องมีความผิด (วินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2809/2516) 3. ศาสตราจารย์
ดร.หยุดแสงอุทัย ได้อธิบายว่า ที่จะเป็นความผิดฐานเป็นตัวการจะต้องเข้าองค์
ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ต้องมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 2) ต้องได้ร่วมกระทำ

ความผิดด้วยกัน และ 3) ต้องได้มีเจตนาที่จะร่วมกระทำความผิดด้วยกัน การกระทำที่จะถือว่าเป็นการร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นต้องเป็นกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปแบ่งงานกันทำ แม้บางคนจะทำมากน้อยต่างกันก็ตาม แต่การกระทำของทุกคนก็เป็นเหตุให้เกิดความผิดขึ้น และถือเสมือนว่า แต่ละคนได้กระทำความผิดนั้นแต่ผู้เดียว (ดู "กฎหมายอาญา ภาค 1, นายหยุด แสงอุทัย, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514, หน้า 97-100") แต่ศาสตราจารย์จิตติติงศภักดิ์ อธิบายว่าการร่วมกระทำความผิดด้วยกันในความผิดอันหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นั้น ต้องพิจารณาทั้งในส่วนการกระทำและในส่วนเจตนาของผู้ที่ร่วมกระทำประกอบกัน หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นการร่วมกระทำความผิดด้วยกัน หมายถึง ก. การกระทำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำทั้งหมดที่รวมกันเป็นความผิดขึ้น แม้ใครจะทำมากน้อยหนักเบาเพียงใดก็ตาม ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น เสมือนทำด้วยตนเองทุกคน ข. การกระทำความผิดแต่ละอันนั้น เป็นสาระสำคัญก่อให้เกิดเป็นความผิดขึ้น ค. การกระทำเสมือนหนึ่งของความผิดอาจได้แก่การแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อให้การกระทำความผิดเป็นผลสำเร็จขึ้นก็ได้ ง. การกระทำเสมือนหนึ่งแห่งการกระทำความผิดอาจรวมถึงการที่อยู่ที่เกิดเหตุในลักษณะที่สามารถช่วยเหลือให้การกระทำความผิดสำเร็จลุล่วงไปเท่านั้นก็ได้ โดยที่ผู้นั้นไม่จำเป็นต้องได้กระทำอะไรลงด้วยมือตนเองด้วย การกระทำส่วนหนึ่งของความผิดดังกล่าว ต้องมีการร่วมในการกระทำความผิด จึงจะถือได้ว่าเป็นการ "ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน" มาตรา 83 คือ เป็นการร่วมกันในระหว่างกระทำความผิดนั้น ในส่วนของเจตนากระทำร่วมกันนั้น ต้องเป็นการกระทำโดยผู้กระทำมีเจตนาร่วมกระทำด้วยกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ และทุกคนที่กระทำจะต้องรู้ถึงการกระทำของกันและกัน และต่างประสงค์ถือเอาการกระทำของแต่ละคนเป็นการกระทำของตนด้วย นอกจากนี้ เจตนาร่วมกระทำด้วยกันนั้น ต้องมีเจตนาร่วมในการกระทำทั้งหมดที่เดียวจะมีเจตนาร่วมด้วย แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่พอ (ดู "คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1

ตอนที่ 1, นายจิตติติงศภัทิย์,แสงทองการพิมพ์ 2517, หน้า 375-412") คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 101/2533 นี้ ได้วินิจฉัยพฤติการณ์ในคดีแล้วเห็นว่าจำเลยเป็นตัวการด้วยโดยอาศัยหลักการต่าง ๆตามที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายเรื่องที่วินิจฉัยในเรื่องการเป็นตัวการในคดีข่มขืนกระทำชำเราไว้ด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2200/2527 ผู้เสียหายไปเที่ยวงานจำเลยที่ 2 ซึ่งผู้เสียหายไม่เคยรู้จักมาก่อนได้เข้ามาทักทายและไปเที่ยวงานด้วยกัน จนกระทั่งดีกผู้เสียหายจะกลับบ้านก็ขอให้จำเลยที่ 2 กับพวกไปส่ง จำเลยที่ 2 ทำริรอว่าจะรอเพื่อนก่อนแต่เมื่อผู้เสียหายเดินออกจากบริเวณงาน ก็เห็นจำเลยที่ 2 กับพวกเดินนำไปก่อน ครั้นถึงที่เกิดเหตุผู้เสียหายก็ถูกชายวัยรุ่นซึ่งมีจำเลยที่ 1 รวมอยู่ด้วยฉุดไปข่มขืนกระทำชำเราที่ข้างทาง ส่วนจำเลยที่ 2 ถอดกางเกงรออยู่ ผู้เสียหายขอร้องว่าอย่าทำหนูเลยจำเลยที่ 2 ตอบว่าอีกคนหนึ่ง แต่มีคนเดินมาคนร้ายจึงอุ้มผู้เสียหายไปที่อื่นแล้วข่มขืนกระทำชำเราจนผู้เสียหายสลบไป ตามพฤติการณ์ส่อว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับพวกเพื่อกระทำความผิดมาแต่ต้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 563/2528 จำเลยที่ 4 ชวน ล. ไปเก็บผักไปถึงที่เกิดเหตุพบจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 รออยู่ เมื่อจำเลยดังกล่าวจะข่มขืนกระทำชำเรา ล. จำเลยที่ 4 ได้ปลีกตัวออกไปจากที่เกิดเหตุและกลับมา เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ข่มขืนกระทำชำเรา ล. เสร็จแล้ว ดังนี้ ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ได้ร่วมกันจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ข่มขืนกระทำชำเรา ล. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1715/2528 ก่อนเกิดเหตุจำเลยอยู่ในกลุ่มของพวกที่ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย และขณะเกิดเหตุจำเลยนั่งอยู่กับพวกที่โต๊ะใกล้ห้องน้ำที่เกิดเหตุ ถือสื่อให้เพื่อนที่เข้าไปข่มขืนกระทำชำเรา และเพื่อดูเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแจ้งเหตุร้ายแก่ผู้กระทำผิด ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยร่วมกระทำผิดแล้ว 4. ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโหมโรงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง นั้น ศาสตราจารย์จิตติติงศภัทิย์ ได้อธิบายว่า คือการร่วมกระทำ คือผู้ลงมือกระทำชำเราต้องมากกว่าหนึ่งคนผลัดเปลี่ยนกันกระทำ อย่างน้อยสองคนคนละครั้ง

ด้วย มิใช่แต่มีตัวการหลายคนเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า แม้จะมีตัวการร่วมกระทำผิด
ข่มขืนกระทำชำเราหลายคนก็ตาม การกระทำนั้นอาจจะเป็นการโทรมหญิงหรือไม่ใช่
ก็ได้ ดังปรากฏตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้ ก. จำเลยเพียง 1 คนข่มขืน
กระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จส่วนจำเลยอื่น ๆ ไม่ได้ข่มขืนกระทำชำเราด้วย กรณี
นี้จะถือว่าจำเลยทั้งหมดเป็นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการ
โทรมหญิงหรือไม่ เรื่องนี้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยกลับไปกลับมาหลายครั้ง
แต่ผลสุดท้ายมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3007/2532(ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่ามีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276วรรคสอง ทั้งนี้มีรายละเอียดแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกาต่าง ๆ ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 250/2510(ประชุมใหญ่) ความ
ผิดในเรื่องข่มขืนกระทำชำเราเป็นความผิดที่ร่วมกันกระทำผิดได้ โดยผู้ร่วมกระทำ
ผิดมิต้องเป็นผู้ลงมือกระทำชำเราด้วยทุกคน เพียงแต่คนใดคนหนึ่งกระทำชำเรา ผู้ที่
ร่วมกระทำผิดทุกคนก็มีความผิดฐานเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 แล้วและตามมาตรา 276ก็หาได้บัญญัติให้ลงโทษเฉพาะชายเท่านั้นไม่ เพราะใช้
คำว่า"ผู้กระทำผิดฯ" เท่านั้น แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นหญิง เมื่อฟังได้ว่าสมคบกับจำเลย
ที่ 1 ร่วมกันกระทำความผิด ศาลก็ลงโทษฐานเป็นตัวการได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่
59/2524 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราหญิง ผู้ร่วมกระทำไม่จำเป็นต้องลงมือกระทำ
ชำเราด้วยกันทุกคน หาได้บัญญัติลงโทษเฉพาะชายเท่านั้นไม่ หญิงซึ่งร่วมกระทำผิด
กับชายผู้กระทำชำเราก็นับเป็นตัวการด้วย หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง 2 เรื่อง
ข้างต้นเป็นการวินิจฉัยในปัญหาว่าหญิงจะเป็นตัวการในความผิดฐานข่มขืนกระทำ
ชำเราได้หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1965/2524 การที่จำเลยลอบเข้าไปข่มขืน
กระทำชำเราผู้เสียหายถึงในห้องจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้งแล้วจำเลยก็ออกจากห้อง
เรียกนายดัดลูกจ้างของจำเลยให้เข้าไปข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายด้วย นายดัด
ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง โดยจำเลยมิได้ร่วมกระทำผิด
ด้วยในตอนนั้น การกระทำของจำเลยเข้าลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามฟ้องหรือไม่

ศาลฎีกาพิเคราะห์สถานที่และการกระทำของจำเลยที่กระทำต่อผู้เสียหายดังกล่าว แล้ว เห็นว่า กรณียังไม่เข้าลักษณะเป็นการโทรมหญิง หมายเหตุ เข้าใจว่าศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดคนละตอนกันมากกว่า จึงไม่ถือว่าจำเลยกับพวก ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3051/2525 จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างทำนาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีพี่สาวผู้เสียหายได้ใช้มีดบังคัมพาผู้เสียหายอายุไม่เกิน 13 ปี ไปยังห้องในอาคารเรียนที่มีดเมื่อกระทำชำเราเสร็จแล้วได้ข่มขู่ให้ลุกขึ้น แล้วออกจากห้องไปจำเลยที่ 1 ก็เข้ามากระทำชำเรา แสดงว่าจำเลยทั้งสองคบคิดกันมาก่อนแม้จะผลัดกันเข้ากระทำชำเรา ก็เป็นการร่วมกันกระทำความผิด แม้อวัยวะเพศของจำเลยที่ 1 มิได้ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายก็ไม่ใช่ข้อสำคัญเพราะต้องรับผิดชอบเป็นการร่วมข่มขืนกระทำชำเราพร้อมกับจำเลยที่ 2 อยู่แล้วและมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 แม้จะไม่สามารถข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายได้ก็เป็นตัวการในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงด้วย แต่ท่านอาจารย์อัมพรนตะกั้วทุ่ง ซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาได้มีหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว่า จำเลยที่ 1 น่าจะมีความผิดเพียงฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันไม่ใช่ลักษณะเป็นการโทรมหญิงเท่านั้น (ดูเนติบัณฑิตยสภา, คำพิพากษาศาลฎีกา ประจำพุทธศักราช 2525 ตอนที่ 10, บริษัทบพิตรการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526, หน้า 2202-2204") คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2449/2527 จำเลยทั้งสองใช้มีดปลายแหลมขู่เข็ญบังคัมพาผู้เสียหายไปที่ปาละเมาะ แล้วผลัดกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ดังนั้นเป็นการโทรมหญิง หมายเหตุ ผู้เสียหายคดีนี้เป็นไปแต่กำเนิดแต่ได้เบิกความโดยใช้มือแสดงประกอบอาการท่าทาง ศาลฎีกาวินิจฉัยตอนหนึ่งว่า "...ศาลฎีกาเห็นว่า นางแดงและนางแผ้วพาผู้เสียหายไปแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในระยะกระชั้นชิดกับเวลาเกิดเหตุซึ่งผู้เสียหายได้แสดงท่าทางให้เป็นที่รู้ได้ว่า จำเลยทั้งสองข่มขืนกระทำชำเราผู้

เสียหายและเมื่อได้ตัวจำเลยทั้งสองมาในคืนเกิดเหตุ ผู้เสียหายก็ชี้ตัวจำเลยทั้งสองว่าเป็นคนร้าย ประกอบกับจำเลยที่หนึ่งให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนและจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นมอบตัวว่าได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ทั้งยังได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำแผนที่เกิดเหตุและแสดงท่าทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายภาพประกอบคำรับสารภาพพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคง แม้ผู้เสียหายจะเบิกความตอบทนายจำเลยโดยยกนิ้วก้อยแล้วยกสองมือประกบกันขึ้น ๆ ลง ๆ จากนั้นยกมือข้างเดียวส่ายไปมา ซึ่งล่ามแปลว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ก็ไม่ทำให้น้ำหนักพยานหลักฐานโจทก์เสียไปข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายด้วยและพฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองใช้มีดปลายแหลมขู่เชือดบังคับลากผู้เสียหายไปที่ป่าละเมาะแล้วผลักดันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายถือได้ว่ามีลักษณะเป็นการโทรมหญิง..." ต่อมาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 227/2529 และ 1202/2529 ได้ตัดสินตามแนวความเห็นของท่านอาจารย์อัมพรตะกั่วทุ่ง ดังกล่าวคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 227/2529 จำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนขู่บังคับหญิงผู้เสียหายให้ยอมให้จำเลยที่ 2 กระทำชำเรา โดยจำเลยที่ 1 มิได้กระทำชำเราผู้เสียหายด้วย ถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง แต่ถือเป็นตัวการร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายโดยมีหรือใช้อาวุธปืนอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ มีหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจของนายเจริญ ภักดีธนากุล อยู่ด้วย โปรดดู"คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2529 เล่มที่ 1,สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ, บริษัทศรีสมบัติการพิมพ์ จำกัด,พ.ศ. 2529, หน้า 60-62" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1202/2529(ประชุมใหญ่) การร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงนั้น ต้องมีการร่วมกันผลักดันเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราตั้งแต่สองคนขึ้นไป จำเลยที่ 1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเพียงคนเดียว จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้ข่มขืนกระทำชำเราด้วย เพียงแต่กอดจูบและกอดผู้เสียหายให้จำเลยที่

1 ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเท่านั้น ลักษณะการกระทำดังกล่าวเป็นเพียงตัวการร่วมกระทำผิดข่มขืนกระทำชำเราด้วยกัน กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นการโทรมหญิง หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นการวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ในปัญหาเรื่องนี้เป็นครั้งแรก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1444/2530 ครั้งแรกผู้เสียหาย ถูกพวกของจำเลยข่มขืนกระทำชำเราในสวนปาล์มโดยจำเลยมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ด้วย หลังจากผู้เสียหายนุ่งกางเกงและเดินมาถึงถนนข้างสวนปาล์มจึงพบกับจำเลย จำเลยได้กอดและลากพาตัวผู้เสียหายไปข่มขืนกระทำชำเราที่ข้างจอมปลวกใหญ่ใน ป่าห้วยคา ดังนี้ จำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่างสถานที่ ต่างเวลาและ ขาดตอนจากการที่พวกของจำเลยกระทำในครั้งแรก จึงหาใช่เป็นการผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสองไม่ คงเป็นความผิดตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ง และมาตรา 278 เท่านั้น หมายเหตุ โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1965/2524 ข้าง ต้นซึ่งวินิจฉัยอ้างเหตุผลคล้ายคลึงกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3007/2532(ประชุมใหญ่) การที่จำเลยกับพวกร่วมกันบุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายในเวลากลางคืน โดย จำเลยมีอาวุธมีดพวกของจำเลยมีอาวุธปืน แล้วจำเลยได้ใช้อาวุธมีดจี้บังคับกระทำ ชำเราผู้เสียหาย ในขณะที่เดียวกันนั้นพวกของจำเลยได้ใช้อาวุธปืนจี้บังคับข่มขืน กระทำชำเราพวกของผู้เสียหายอีกคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนเตียงเดียวกันนั้น จำเลยมี ความผิดฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยขู่เข็ญใช้กำลัง ประทุษร้ายและได้ร่วมกันกระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง เมื่อจำเลยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายแล้ว พวกของจำเลย ได้ผลจากพวกของผู้เสียหายมาข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่ออีกแม้พวกของ จำเลยจะไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายได้ แต่ก็ได้ ลงมือกระทำการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนถึงขั้นพยายามแล้ว การที่จำเลยกับ พวกผลัดเปลี่ยนกันกระทำชำเราผู้เสียหายต่อเนื่องกัน ถือได้ว่าเป็นการร่วมกัน

กระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง หมายเหตุ ความในวรรคที่สอง เป็นการวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งกลับหลักในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1202/2529(ประชุมใหญ่) ข้างต้น ข้อเท็จจริงคดีนี้ฟังยุติได้ว่าผู้กระทำผิดมีเพียง 2 คน คือจำเลยกับพวกอีก 1 คน ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่า "...เมื่อจำเลยกระทำชำเรานางสาว ศรีนวลจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง แล้วพวกของจำเลยก็ได้เข้าไปข่มขืนกระทำชำเรา นางสาวศรีนวลอีก แสดงให้เห็นว่าจำเลยกับพวกได้คบคิดกันมาก่อน และในขณะที่เกิด เหตุก็ได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานางสาวศรีนวลด้วยกัน แม้พวกของจำเลยจะไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในอวัยวะเพศของนางสาวศรีนวลและเด็กหญิง นงนุชได้ แต่ก็เป็นที่เห็นได้ว่าพวกของจำเลยได้ลงมือกระทำการข่มขืนกระทำชำเรา นางสาวศรีนวลและเด็กหญิงนงนุชจนถึงขั้นพยายามแล้วดังนั้น การที่จำเลยกับพวก ผลัดเปลี่ยนกันกระทำชำเรานางสาวศรีนวลต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นการรุมกันกระทำการ ข่มขืนกระทำชำเราต่อนางสาวศรีนวล กรณีนี้ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันกระทำ